

1500421-90.2020.8.26.0558

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... em crimes de elevada gravidade como o de tráfico de drogas, cujas testemunhas se abstêm de prestar declarações às autoridades policial ou judicial por respeito à "lei do silêncio" e por temor a represálias. Nesse sentido, a propósito, é a pacífica posição da jurisprudência do E. TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Preliminar de cerceamento de defesa, no caso, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1231 1500421-90.2020.8.26.0558 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500421-90.2020.8.26.0558

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2264159/2020 - DEL.INV.GER.

CATANDUVA, 14308920 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 589/20/121 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2264159 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHEL FERNANDO RODRIGUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Michel Fernando Rodrigues dando-o como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06, pois, no dia 23 de outubro de 2020, por volta das 15h30, na Rua Belo Monte, n. 221, Parque Residencial Agudo Romão, nesta cidade e Comarca, ele trazia consigo e guardava, para fins de mercancia, quarenta e oito pinos de cocaína, quando restou surpreendido por ação deflagrada pela Polícia Militar (fls. 92/93).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 24 de outubro de 2020 (fls. 49/52).

A defesa preliminar não abordou o mérito (fls. 185/187), a denúncia foi recebida (fl. 193) e o acusado citado (fl. 225).

No curso da instrução foram ouvidas três testemunhas e interrogado o acusado, que negou a prática delitiva.

Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram e,

em alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da pretensão punitiva estatal (fl. 336/340), ao passo que a Defesa, preliminarmente, suscita a invalidade do depoimento da testemunha "Alpha I", e, no mérito, roga pela absolvição em razão da insuficiência probatória (fls. 363/373).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Antes de ingressar no mérito da demanda, é de rigor a análise da questão preliminar aventada pela Defesa, notadamente de nulidade do depoimento prestado virtualmente, eis que a testemunha estaria acompanhada e sendo instruída em suas declarações. Cumpre perceber que a alegação sob análise é reiteração de impugnação formulada pela Defesa por ocasião da audiência e que foi superada pelo magistrado presidente do ato – como bem consta das alegações defensivas e se depreende da mídia de fl. 349.

Ademais, de rigor salientar que, em última análise, as declarações prestadas em Juízo pela testemunha reproduzem àquelas por ela prestadas à autoridade policial (fl. 99), notadamente no sentido de que não acompanhou toda a abordagem policial, assim como não vislumbrou o encontro de drogas pelos agentes públicos.

De todo modo, eventuais desvios de olhar da testemunha, titubeações ou comportamentos afins – não raros em testemunhas de processos judiciais – não impregna o ato judicial, mas tão somente tolhe seu valor probatório, que deve ser sopesado com os demais elementos de convencimento carreados.

Nesse sentido, a propósito, é o voto do Des. Guilherme de Souza Nucci nos embargos de declaração criminal n. 1500207-72.2020.8.26.0567:

De qualquer modo, ainda que assim não fosse, a eventual quebra de incomunicabilidade sequer devidamente comprovada deve ser vista com reservas, sobretudo durante o período atual vivido pela sociedade em decorrência da pandemia do coronavírus, que modificou a sistemática de trabalho presencial e obrigou, de um momento para outro, a realização de audiências virtuais, a fim de permitir o regular andamento dos processos, muitas vezes sem a estrutura necessária para tal finalidade, devendo eventuais falhas procedimentais durante o aludido ato processual ser valoradas como meras irregularidades, sobretudo quando não demonstrado o efetivo prejuízo à parte suscitante.

Na mesma linha:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo. PRELIMINAR. Apelo em liberdade prejudicado pelo julgamento colegiado. Quebra de incomunicabilidade de testemunhas não comprovada. Rejeição. ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Eventual desclassificação para uso inviável. DOSIMETRIA. Penas corretas. Inaplicabilidade da benesse do CP, art. 44. Regime fechado preservado. DESPROVIMENTO. (TJSP; Apelação Criminal 1500276-25.2020.8.26.0270; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeva - 3ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021) Assim, rejeito a questão preliminar.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito. Diante do arcabouço probatório produzido, a pretensão punitiva deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 10), pelos laudos de constatação preliminar e definitiva de substância entorpecente (fls. 12/14 e 172/174) e por todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos.

Por seu turno, a autoria também é certa e repousa sobre o ora réu.

Com efeito, os policiais militares Carlos Alberto Vicente Camargo e Wilian Ayres Nascimento, em Juízo, declararam que já possuíam informações de que o ora acusado realizava a comercialização de drogas em sistema de delivery, valendo-se, para tanto, de uma motocicleta. Disseram que na data dos fatos avistaram a motocicleta e iniciaram perseguição, até que o alcançaram e o submeteram à revista pessoal, ocasião em que apreenderam vultosa quantia em dinheiro e quarenta e oito pinos de cocaína. Responderam que foram até a residência do réu e lá encontraram mais uma porção de maconha. Explicaram que foi necessário o emprego de força física em

virtude da resistência do réu.

A testemunha protegida, qualificada como "Alpha 1", disse que estava próxima ao local em que ocorreu a abordagem do acusado e que não vislumbrou o encontro de drogas pelos agentes públicos.

Por ocasião de seu interrogatório, o acusado negou a prática do crime. Aduziu que na data dos fatos se deslocava com o intuito de adquirir um presente para a sua namorada até que, em dado momento, passou a ser perseguido por policiais militares, razão pela qual decidiu conduzir a sua motocicleta até um local movimentado, qual seja um posto de gasolina. Disse que foi agredido fisicamente e psicologicamente e que nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Negou que tenha autorizado os policiais a ingressar em seu domicílio e que no local havia apenas uma pequena porção de maconha destinada ao consumo pessoal.

Ocorre que a detida análise dos elementos informativos e probatórios carreados nos autos permite inferir que a negativa trazida pelo réu se mostra demasiadamente insulada nos autos, pois não é corroborada por documentos, testemunhas ou qualquer outra notícia formalmente inserida no caderno processual – além do que exige pressupor que as drogas apreendidas foram criminosamente plantadas pelos agentes públicos em seu desfavor, tudo, frise-se, sem qualquer base probatória.

Lado outro, os testemunhos dos policiais militares são firmes, uníssonos, detalhados e coesos.

No ponto, conquanto não sejam dotados de presunção processual de veracidade nem possuam valor probatório superior às demais provas admitidas no campo do processo penal, os testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão não podem ser indistintamente desconsiderados tão somente pela natureza da função que exercem, sobretudo quando coesos e uniformes, como no caso. Ademais, não se pode olvidar que nas ações penais lastreadas em autos de prisão em flagrante corriqueiramente as únicas testemunhas são exatamente os policiais responsáveis pela prisão, especialmente em crimes de elevada gravidade como o de tráfico de drogas, cujas testemunhas se absterem de prestar declarações às autoridades policial ou judicial por respeito à "lei do silêncio" e por temor a represálias. Nesse sentido, a propósito, é a pacífica posição da jurisprudência do E. TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Preliminar de cerceamento de defesa, no caso, confunde-se com o mérito. Ausência de prova do prejuízo. Absolvição.

Materialidade e autoria comprovadas. Conjunto probatório firme e seguro a demonstrar a destinação mercantil da droga. Valorização das palavras dos policiais responsáveis pela prisão dos réus. Impossibilidade de desclassificação do crime para o de porte para uso próprio. Penas inalteradas. Artigo 41 da Lei de Drogas.

Afastamento. Réu não colaborou com as investigações. Regime prisional mantido no fechado. APELO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500606-18.2020.8.26.0530;

Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cajuru - Vara Única; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição. Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Razoável quantidade de drogas e circunstâncias da prisão – Reprimenda.

Redução. Afastamento da circunstância judicial desfavorável. Quantidade de droga que não pode ser considerada expressiva – Apelo parcialmente provido. (TJSP;

Apelação Criminal 1500097-75.2019.8.26.0610; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Morro Agudo - Vara Única; Data do Julgamento: 13/11/2020; Data de Registro: 13/11/2020)

No caso, a Defesa não apresenta qualquer elemento objetivo que possa colocar em dúvida a imparcialidade dos agentes públicos e a veracidade dos seus depoimentos, que, frise-se, são firmes, coesos e uníssonos, além de corroborados e confirmados pelos demais elementos informativos e probatórios disponibilizados nos autos, dentre os quais vale destacar, uma vez mais, a apreensão das substâncias entorpecentes.

As testemunhas "Alpha 1" e "Alpha 2", já em sede policial, não prestaram informações esclarecedoras dos fatos, pois negaram que tenham assistido à revista pessoal, o que pressupõe que não assistiram à apreensão de drogas armazenadas na

cueca do acusado e sequer mencionam a apreensão de dinheiro – o que é incontroverso nos autos (fls. 99 e 100).

O fato de não terem sido capazes de acompanhar as buscas ao longo de toda a abordagem torna inviável que se conclua pela caracterização de eventual flagrante forjado.

De mais a mais, a forma de armazenamento e acondicionamento das substâncias (quarenta e oito pinos de cocaína), a apreensão de vultosa quantia, os antecedentes do acusado, que figura como imputado em outra ação penal por tráfico de drogas, e as prévias informações ostentadas pelos policiais acerca da traficância, permitem concluir que o material tóxico não era destinado ao consumo pessoal, e sim à comercialização. Incabível, destarte, a desclassificação da imputação penal. Destarte, tanto a existência quanto a autoria do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 estão cabalmente comprovadas nos autos, não havendo se falar em insuficiência probatória ao decreto condenatório, aplicação do princípio do in dubio pro reo ou mesmo desclassificação. A prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe. Passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP.

Na primeira fase, em análise ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 e no art. 59 do CP, conclui-se que, a natureza e a quantidade da substância traficada não revelam desvalor anormal. A culpabilidade, tida como o grau de reprovabilidade do comportamento, é ínsita ao tipo penal. Ausentes condenações definitivas hábeis a configurar Maus Antecedentes. Ausentes provas acerca da conduta social do agente. A personalidade é circunstância neutra ante a falta de amparo probatório. O motivo do crime é próprio à espécie, assim como as suas circunstâncias e consequências. Não há comportamento de vítima a ser valorado. Logo, fixo a pena-base no patamar mínimo, qual seja 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes de pena. Mantenho, por consequência, a pena intermediária no patamar mínimo legal.

Na terceira e derradeira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento. Registre-se que não cabe, no caso, a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, porquanto não preenchidos integralmente os requisitos para tanto, eis que se depreende dos autos a dedicação do acusado às atividades criminosas.

Com efeito, embora seja primário e ostente bons antecedentes, os policiais possuíam informações de que ele realizava a traficância de drogas mediante sistema de delivery, ou seja, com frequência e reiteração.

Ademais, e principalmente, o acusado ostenta condenação em primeira instância, já confirmada em instância superior, proferida nos autos n. 1500255-75.2020.8.26.0132, por tráfico de drogas praticado aproximadamente nove meses antes do fato em análise.

No ponto, é sabido que a utilização de ações penais em andamento para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico de drogas é objeto de divergência no âmbito jurisprudencial. Ocorre que, além de haver firme posição pela sua admissibilidade (já que o próprio dispositivo legal diferencia reincidência, Maus Antecedentes e dedicação a atividades criminosas), as situações do caso concreto justificam a sua invocação, eis que permitem afastar a tese de que o agente pode ser considerado “pequeno e eventual traficante”.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 43 da Lei 11.343/06 c.c art. 49, §1º, e 60 do CP), ante a ausência de informações sobre a capacidade econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto. Isso porque a reprimenda privativa de liberdade aplicada é inferior a oito anos, o agente é primário, as circunstâncias judiciais são integralmente favoráveis e a prisão cautelar já perdura por inaceitáveis vinte e seis meses (art. 33, §2º, 'b', do CP, art. 387, §2º, do CPP e Súmula 440 do STJ). Destaque-se, no ponto, que de acordo com o teor da referida Súmula, “fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito”.

Ainda em vista da natureza da infração, da reincidência e da quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, inviável a sua substituição por restritiva de direitos ou sua suspensão condicional (art. 44, I e II, e 77, I, do CP, e art. 44 da Lei 11.343/06).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado Michel Fernando Rodrigues como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06, à reprimenda de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente à época do fato.

Por se tratar de crime vago, não há se falar em fixação de valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Porquanto permanecem hígidos os cenários fático e jurídico que outrora ensejaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva, mantenho a medida cautelar. Com efeito, enquanto o fumus comissi delicti resta verificado em sede de cognição exauriente, o periculum in libertatis é extraído da reiteração delituesa, que ocasiona severo e concreto risco à ordem pública. Logo, a segregação cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, motivo pelo qual, com fulcro no art. 387, §1º c.c 311, 312 e 313, I, do CPP, mantenho a prisão preventiva.

Todavia, a medida cautelar deverá ser adaptada ao regime de pena imposto na sentença, qual seja o semiaberto, a fim de evitar violação ao princípio da homogeneidade e constrangimento ilegal. Nessa linha, conquanto haja severa controvérsia a respeito do tema nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial, prevalece no âmbito do C. STJ que “Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que haja a devida adequação da custódia com o regime fixado”. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE EXPLOÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. QUATRO ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO.

REGIME SEMIABERTO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.

NÃO VIOLAÇÃO. FUNDAMENTOS DA PREVENTIVA. PRESENTES. MEDIDAS CAUTELARES

ALTERNATIVAS. INCABÍVEIS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA

NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 8. Em

relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao recorrente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. No caso dos autos, foi proferida sentença condenatória em desfavor do paciente, fixando o regime semiaberto para o

cumprimento da pena que lhe foi imposta. Na oportunidade, foi determinada a expedição de carta de sentença para a Vara de Execuções Penais, independentemente

do trânsito em julgado, de forma a assegurar o recolhimento em estabelecimento penal compatível, bem como os benefícios da execução. Não há, portanto, que se

falar em violação ao princípio da homogeneidade. 9. De mais a mais, de acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, não há incompatibilidade entre a

negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. [...] 12. Agravo

regimental desprovido. (AgRg no RHC 143.846/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 08/04/2021)

Na mesma trilha se verificam julgados do E. TJSP:

Habeas Corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput). Insurgência contra decisão que após condenar o paciente à pena de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto,

manteve a prisão preventiva. Por mais que se reconheça a divergência

jurisprudencial a respeito do tema, o próprio juízo de origem indicou em sua decisão que a custódia cautelar era adequada ao regime estabelecido em sentença, o

que de fato aconteceu em 27.10.2021. Referida providência encontra respaldo na jurisprudência recente do C. STJ que afirma que não há incompatibilidade entre a

negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que haja a devida adequação da custódia com o regime fixado. Constrangimento

ilegal não verificado no caso concreto. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus

Criminal 2240003-47.2021.8.26.0000; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Joaquim da Barra - 1ª Vara;

Data do Julgamento: 08/11/2021; Data de Registro: 08/11/2021)

Assim, recomende-se o réu à prisão, com determinação de imediata adaptação da cautelar ao regime semiaberto.

Condene o acusado, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, sem embargo da suspensão da exigibilidade do encargo em razão da aplicação analógica do art. 98, §3º, do CPC c.c art. 3º do CPP.

Em observância ao art. 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das amostras de substância entorpecente guardadas para contraprova, com certificação nos autos, e, com base no art. 63, I, da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do numerário apreendido nos autos.

Ademais, com fundamento no art. 243, parágrafo único, da CF, e no art. 63, I, da Lei 11.343/06, decreto o perdimento da motocicleta Honda/CG 150FAN, de placas FUB2388, apreendida à fl. 10. Isso porque, como já restou assentado, o automóvel foi instrumento utilizado pelo acusado para a prática do tráfico de drogas. De mais a mais, o STF já sedimentou o entendimento de que, para o decreto do confisco, é prescindível o emprego habitual do bem na prática criminosa ou a adulteração de suas características:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 647 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO APREENDIDO COM O SUJEITO ATIVO DO CRIME. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO BEM. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXIGÊNCIA DE HABITUALIDADE DO USO DO BEM NA PRÁTICA CRIMINOSA OU ADULTERAÇÃO PARA DIFICULTAR A DESCOBERTA DO LOCAL DE ACONDICIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (...) 9. Tese: É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 10. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. (RE 638491, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)

Proceda-se às comunicações de praxe, inclusive no que tange ao perdimento de bens. Com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF), intime-se o réu para pagamento da multa no prazo de dez dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP) e expeça-se a guia de execução, assim como o que mais for cabível.

P. I. C., com observância do art. 392 do CPP.

Catanduva, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA